

Sentenza del Consiglio di Stato n. 4540/2024 (Sezione Quinta)

Pubblicata il 22 maggio 2024

Contesto della Controversia

Il Comune dell'Aquila ha indetto una procedura di co-progettazione con il Terzo Settore, ai sensi del **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)** e del **D.M. 72/2021**, per l'affidamento del servizio di **"Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione dei diversamente abili nelle scuole del Comune"**.

La **Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti**, che era il gestore uscente del servizio, ha impugnato la procedura dinanzi al **TAR Abruzzo**, sostenendo che fosse illegittima perché:

1. Non era stata preceduta dalla necessaria fase di **co-programmazione**.
2. Il servizio era stato impostato come **un appalto**, piuttosto che una vera co-progettazione.
3. La decisione di utilizzare la co-progettazione invece dell'appalto doveva essere presa dal **Consiglio Comunale** e non da un dirigente.
4. L'avviso pubblico predeterminava nel dettaglio il servizio, escludendo quindi un effettivo contributo progettuale da parte del Terzo Settore.
5. L'obbligo di avere **bilanci in utile negli ultimi due anni** non considerava gli effetti della pandemia COVID-19.

Il **TAR Abruzzo** ha accolto il ricorso, annullando la procedura per **incompetenza del dirigente comunale**, che avrebbe violato il Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 (PSD), il quale prevedeva che il servizio di assistenza scolastica fosse affidato tramite **appalto** e non con **co-progettazione**.

Decisione del Consiglio di Stato

Il **Comune dell'Aquila** ha impugnato la sentenza del TAR davanti al **Consiglio di Stato**, sostenendo che:

- Il TAR avrebbe accolto il ricorso su motivi non sollevati dalla cooperativa (vizio di **ultrapetizione**).
- Il Piano Sociale Distrettuale non escludeva la possibilità di affidare il servizio con **co-progettazione**.
- Il **Regolamento comunale** del 2022 sulla co-progettazione permetteva il ricorso a questa modalità.

Dopo aver riesaminato la questione, il **Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune** e confermato la sentenza del TAR, ma con motivazioni diverse.

Motivazioni Principali del Consiglio di Stato

1. **La procedura seguita dal Comune non rispettava i criteri della co-progettazione:**

- Il **Bando** e il **Capitolato tecnico** definivano nel dettaglio il servizio (numero di ore, tipologia di utenti, caratteristiche degli operatori, luogo di esecuzione, modalità di pagamento, penali, garanzie).
- La procedura assomigliava più a un **appalto di servizi** che a una co-progettazione.
- Il contributo del Comune prevedeva il **pagamento dietro emissione di fattura**, elemento tipico di un contratto sinallagmatico (tipico dell'appalto) e non di un partenariato.

2. Violazione della normativa sulla co-progettazione:

- La **Corte Costituzionale (sentenza n. 131/2020)** ha chiarito che la co-progettazione deve essere un **modello collaborativo e non un meccanismo competitivo simile agli appalti**.
- La co-progettazione non deve basarsi su **prezzi o corrispettivi**, ma su una **mesa in comune di risorse** tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo Settore.
- Il **D.M. 72/2021** stabilisce che il servizio non deve essere già definito nei dettagli dall'ente pubblico, ma costruito insieme agli enti partner.

3. Il Comune ha violato il concetto di “gratuità” previsto dal Codice del Terzo Settore:

- **Art. 56, D.Lgs. 117/2017**: le convenzioni con gli ETS possono prevedere **solo il rimborso delle spese documentate**, escludendo qualsiasi forma di profitto o remunerazione.
- Il pagamento dietro **fatturazione** dimostra che si tratta di un corrispettivo economico, assimilabile a un appalto e non a una co-progettazione.

4. Conseguenze dell'illegittimità:

- La sentenza del TAR viene **confermata**, ma con motivazioni diverse: il vizio principale non è l'incompetenza del dirigente, ma il fatto che la procedura fosse **un appalto mascherato da co-progettazione**.
- Le spese processuali sono **compensate** tra le parti.

Implicazioni della Sentenza

- **Chiarisce i limiti tra co-progettazione e appalto**: se l'ente pubblico definisce nel dettaglio il servizio e stabilisce un pagamento su base contrattuale, **non può ricorrere alla co-progettazione**.
- **Conferma la necessità di coinvolgimento reale del Terzo Settore**: la co-progettazione non può essere solo un formalismo, ma deve prevedere **una vera collaborazione** nella costruzione del servizio.
- **Ribadisce che la co-progettazione non può essere utilizzata per eludere le gare d'appalto**, specie se il servizio è ad “alta soglia di accesso” e deve essere erogato con modalità predefinite.